

1501601-68.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501601-68.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2331819/2021 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 21802302 -

DEL.SEC.ITAPETININGA, 7021/21/300 - DEL.SEC.ITAPETININGA

Réu:

FABRICIO LYRA OLIVEIRA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP e Art. 35

"caput" do(a) SISNAD c/c Art. 69 "caput" do(a) CP (Denúncia)

Data da Audiência:

27/04/2022

Em 27 de abril de 2022, às 15:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu FABRICIO LYRA OLIVEIRA e LAIS CRISTINA MARQUARDT, bem como o Defensor Técnico dos réus, DR. Mauricio Elias de Almeida Tambelli OAB 241061/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas PM Richard Oliveira Costa e ALISON ARCANJO ALMEIDA NUNES (PMRV). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos

prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus FABRICIO LYRA OLIVEIRA e LAIS CRISTINA MARQUARDT, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei 11.343/06, eis que: 1) no dia 6 de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 19h50, na Rodovia SP 127, Km 134, na cidade de Morro do Alto, Comarca de Itapetininga, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, transportavam e traziam consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, ½ (meio) "tijolo" de Cannabis sativa L e mais 1 porção grande da mesma droga, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto total aproximado de 341,15 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, faziam uso do veículo FIAT MOBI, Placas FRA5113/Sorocaba (SP), com o qual transportavam grande quantidade de "maconha", para posterior entrega ao consumo de terceiros. Policiais Militares efetuavam fiscalização de rotina no pedágio do Morro do Alto quando deram ordem de parada ao condutor do FIAT MOBI, que trafegava sentido Tatuí/Itapetininga. LAIS - que estava ao volante e levava FABRICIO como passageiro - de pronto obedeceu e estacionou o veículo. Ao perceber a aproximação dos Policiais, o acusado tentou esconder as drogas que trazia consigo embaixo do banco do passageiro, em comportamento suspeito, o que despertou a atenção dos Policiais. Diante disso, os Policiais ordenaram que os acusados descessem do veículo e, efetuando buscas, lograram encontrar 1/2 tijolo de "maconha" e mais 1 porção grande da mesma substância sob o banco dianteiro do passageiro, drogas que pertenciam aos denunciados e estava destinada ao tráfico ilícito, que ambos praticavam de forma associada. Os réus foram notificados e apresentaram Defesa Preliminar (fls. 116/145). Assim, por decisão proferida no dia 11 de abril de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 146/149). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com os interrogatórios dos réus, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição dos réus, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 44/45 e 47/48, bem como Certidões a fls. 43 e 46. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e

doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: “(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado transportava substância entorpecente, não há prova suficiente de que tenha se associado a ré para fins de traficância. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, tampouco houve apreensão de instrumentos para o fracionamento da droga (o que revelaria que a conduta dos acusados não se esgotava no transporte do entorpecente), muito menos foram localizadas anotações de contabilidade, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre o réu e a acusada, imperiosa a absolvição deles no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em relação à imputação pelo crime de tráfico de entorpecentes, o pedido merece ser desclassificado para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 e julgado improcedente em relação a ré Lais. Vejamos: A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 30/34), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 41/42), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 165/168) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. O réu, em solo policial (fls. 09), afirmou que é professor de química e leciona no Anglo de Itapetininga e em Piedade, enquanto que sua esposa LAIS é professora de matemática em Piedade. Afirmou ser usuário de maconha e que compra semestralmente a droga em porção que possa ser utilizado por seis meses. Pegou em quantidade maior pois também iria trazer para um cunhado que também é usuário. Sua esposa não é usuária. Afirmou ter comprado em maior quantidade, pois o preço era menor. A droga que foi apreendida em ele custou R\$ 750,00 no total, comprando de um desconhecido em Tatuí e que foi entregue por moto boy, combinado via telefone. Em juízo, disse que não é traficante, que é usuário de maconha, que comprou uma quantidade para ficar por um período grande. Sabia que tinha droga no carro, que teria consequência no seu trabalho, tanto é que foi demitido em uma das escolas que ele trabalhava. Trabalha como professor e trabalhava em duas escolas. Tem renda de quatro mil reais, trabalha em escolas particulares. Confirma que compra a droga em Tatuí, por causa do preço. Mora em Alambari. Tem 42 anos. Nunca teve passagem. Pagou R\$750,00 pela droga. Não achava que era tanta droga e falou que dividiria com outros usuários para melhorar as coisas para ele. A droga na verdade é para ele. Fuma diariamente. Lais não é usuária. Sabia que ele tinha ido

até Tatuí para ver uma amiga, daí saiu para comprar pão e comprou a droga. Ela sabia que ele usava, comprava, mas naquele dia ela não sabia, pois não teria ido com ele. De outro lado, a acusada, em solo policial (fls. 10), afirmou que não usa drogas e que o veículo está em nome dela. É casada com FABRICIO há 9 anos e é professora de matemática em Piedade. Afirmou que foram abordados por policiais rodoviários que encontraram as drogas. Não sabe a quantia exata. Afirmou que o acusado foi até a casa de uma amiga em comum, Débora, professora de português em Tatuí. Em juízo, disse que não sabia que o réu tinha aquilo no carro e foi surpreendida, ficou extremamente nervosa. Foram até Tatuí, almoçaram, ele saiu para ir a padaria e não sabe se nesse momento ele comprou a droga. Sabia que ele era usuário de maconha. Não sabe quando ele compra. Não é usuária e não tem interesse em saber onde ele compra e ele não também não lhe conta. É professora de matemática, dá aula em Piedade no anglo, ganha cerca de R\$2600,00. É professora há 02 anos, pois primeiro deu aula no estado. Nunca foi processada. Analisando a autodefesa dos acusados - colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - observo que o réu admitiu a posse das drogas, mas negou a destinação comercial dos entorpecentes, bem como que ambos negaram o envolvimento da ré. O Policial Militar Richard Oliveira Costa, em sede policial (fls. 07), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em fiscalização de rotina na praça de pedágio Morro do Alto, quando observou um veículo Fiat Mob trafegando sentido Tatuí a Itapetininga e, de maneira aleatória, ordenou para que aquela motorista e veículo parasse as margens para verificação dos documentos. Quando se aproximaram da janela da motorista, notou que o passageiro escondia algum objeto sob o banco do passageiro dianteiro despertando atenção, inicialmente imaginando que fosse alguma arma. Diante de tal situação, ordenaram para que ambos ocupantes descessem do veículo e assim pudesse vistoriar o que escondiam. Então, em busca veicular, logrou êxito em apreender sob o banco dianteiro passageiro meio tijolo de maconha prensada, devidamente embalada em plástico azul e mais uma porção grande de maconha, também envolvida em plástico transparente. Instado, o passageiro informou que era usuário de drogas e que teria ido em Tatuí buscar essa quantidade de droga para dividir com mais outras duas pessoas. Ele teria um grupo de pessoas que comprem quantidade maior para divisão e preço menor. Por sua vez, a motorista disse que sabia que o passageiro era usuário de droga e que apenas transportava o seu companheiro. Informaram que são professores da rede Anglo. Com os acusados também foram apreendidos celulares. Em juízo, estavam em fiscalização numa praça de pedágio na cidade de Morro Alto, perceberam que o réu tentava esconder algo no banco, foi solicitado que descessem, sendo localizado o entorpecente. Fabricio alegou que foram até Tatuí e adquiriram a droga de uma pessoa chamada Débora e que levariam para cidade que residiam e distribuiriam entre outros amigos, pois adquirindo uma porção maior ficaria mais barato para o consumo. Lais estava nervosa no momento da abordagem, ela disse que sabia que seu esposo era usuário de drogas e que foram buscar o entorpecente em Tatuí. A princípio seria uma abordagem de trânsito. Convergindo em mesmo sentido, o Policial Militar Alison Arcanjo Almeida Nunes, em sede policial (fls. 08), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, o policial disse que estavam em fiscalização pela praça de pedágio, quando foi dada ordem de parada ao veículo, solicitado documento de porte obrigatório e neste momento verificaram que o passageiro tentou esconder algo. Em busca no veículo sob o banco foi encontrado um tablete da substância maconha. Confirma que o réu Fabricio disse ter adquirido a droga em Tatuí, e que dividiram a droga entre outros consumidores. A ré Lais disse que sabia que o réu comprava droga em Tatuí para dividir entre outros usuários. Pois bem, não se discute que a quantidade de entorpecentes - maconha, transportada pelo réu, seja elevada, eis que se trata de 341,15 gramas de canabissativa. Mas há em favor dos réus inúmeros outros elementos que tornem duvidosa o envolvimento dos réus como traficantes - ambos são professores em atividade, com renda mensal fixa e razoável para os padrões nacionais, não ostentam quaisquer passagens em sede criminal, não eram conhecidos dos meios policiais, não recaía qualquer denúncia sobre ambos e não foram abordados em situação típica de venda de entorpecentes. Quanto ao entorpecente, não estava embalado em variedade de

porções e era único - meio tablete de maconha. Em relação ao entorpecente por ele transportado, também não se nega que seja substância entorpecente suficiente aos fins de tipificação no artigo 33, caput da Lei 11343/06, mas não se pode negar seu uso amplamente difundido na sociedade e até mesmo estimulado pelos meios midiáticos. Desnecessário seria ainda dizer dos inúmeros países que tem adotado a liberação do uso de maconha, eis que, como já dito, em nosso ordenamento a substância é proibida, argumentando-se apenas para admitir que o réu estivesse com tal quantidade de entorpecente para fins de uso. Não se pode aqui estabelecer um prejulgamento sobre o réu, com base exclusiva na quantidade da droga. Urge que as provas sejam inequívocas ao apontamento de que naquela oportunidade o réu praticava o ilícito penal, ou seja, que aquele entorpecente se destinava a entrega a terceiros, com evidente contraprestação. A quantidade da droga não pode como elemento único e individualizado servir como pilar de um édito condenatório. Sobre o valor probatório dos indícios e das presunções no processo penal, deve-se salientar que "uma condenação criminal, com todos os seus gravames e conseqüências, só pode ser considerada com apoio em prova cabal e estreme de dúvidas, sendo que as presunções e indícios, isoladamente considerados, não se constituem em prova dotada dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência da denúncia" (TACRIM-SP - 1ª Câ. - Ap. 677.133/6 - Rel. PIRES NETO - RJD 17/149). E ainda, segue a jurisprudência: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tráfico de entorpecente - Pequena quantidade apreendida com o réu, que afirma destinar-se ela ao próprio uso - Ausência de prova em sentido contrário - Desclassificação operada - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76" (RT 561/371). Destarte, há que se concluir que o contexto probatório não é robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, para a configuração do crime tipificado no art.33, da Lei nº 11.343/06. Todo esse quadro autoriza o decreto condenatório de forma parcial, uma vez que não restaram dúvidas de que realmente o réu trazia consigo substância entorpecente, que deve ser considerado para seu próprio uso, pela ausência de provas robustas da traficância, consoante a) o coeso e seguro depoimento dos policiais militares b) laudo de exame químico-toxicológico (fls. 165/168) e c) confissão do réu. Em relação a ré LAIS, a prova também se mostra indiciária quer para sua condenação como incurso no artigo 33, caput, quer como incurso no artigo 28, ambos da Lei 11343/06, eis que, o réu assumira a propriedade do entorpecente para o próprio uso, sem que se possa estender a tipificação do crime a ré pelo simples fato de encontrar-se no veículo de seu marido. A ré declarou que é professora em atividade e nem mesmo uso de entorpecentes faz. Certo, portanto, que o réu FABRICIO perpetrou o crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Na falta de antecedentes e de outras informações sobre as suas circunstâncias judiciais que são desfavoráveis e apontam sua personalidade transgressora (fls. 75), com base no art.27, c.c. art.28, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06 fixo cumulativamente as penas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos II e III), pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, na forma do § 3º do referido art.28. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para: a) absolver a ré LAIS CRISTINA MARQUARDT, devidamente qualificados nos autos, da imputação de infringência ao artigo 33, caput da Lei 11343/06 nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; b) absolver os acusados LAIS CRISTINA MARQUARDT e FABRICIO LYRA OLIVEIRA, qualificados nos autos, da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) desclassificar a imputação pelo artigo 33, caput e condenar o réu FABRICIO LYRA OLIVEIRA como incurso no artigo art.27, c.c. art.28, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06 fixo cumulativamente as penas de prestação

de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos II e III), pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, na forma do § 3º do referido art.28. Defiro o Apelo em Liberdade, na medida em que o réu não fora condenado a pena de prisão. Diante da sucumbência parcial, fica o réu obrigado a

recolher as custas de 50 UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total das custas processuais. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Libere-se o veículo apreendido a fls. 12 ao legítimo proprietário e/ou possuidor. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor dos acusados e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA